

제48회 특허법 기출문제 해설 (김남혁 변리사)

I. 문제의 소개

<A-1>

출원 전 공지등이 된 발명에 의해 당업자가 용이발명 가능한 발명은 법 목적상 등록받을 수 없다. (제29조 2항) 진보성은 주관적 창작성을 의미하며 사실판단이 아닌 법적 판단의 문제이다.

II. 설문(1)에 대하여 - 진보성 판단의 일반적인 순서 및 '용이도출' 여부의 판단방법

1. 진보성 판단의 일반적인 순서

i) 제29조 2항 중 '제1항의 규정에도 불구하고'의 해석결과 성립성, 산업상 이용가능성 및 신규성을 만족하는 발명이 진보성의 판단대상이 되며 判例는 청구항에 기재된 발명이 신규성이 없는 경우 그 사유만으로도 특허를 받을 수 없으므로 진보성에 대한 판단을 할 필요가 없다고 한다. ii) 우선, 청구항에 기재된 발명을 특정하고 iii) 인용발명(복수의 인용발명 특정가능)을 특정한다. 인용발명이란 제29조제1항 각호의 1에 규정된 발명이다. iv) 그 후, 청구항에 기재된 발명과 가장 가까운 인용발명을 선택하고 v) 양자 대비하여 발명의 구성요소 간의 유기적 결합성을 감안하여 차이점을 명확히 한다. (判例 역시 진보성 판단에 있어 인용발명의 대비대상은 청구범위의 기재라 한다) vi) 선택된 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명이 당업자로부터 용이한지를 다른 인용발명과 출원전의 기술상식 및 경험적 등에 비추어 판단한다.

2. '용이도출 (용이하게 발명할 수 있는지)' 여부의 판단방법

(1) [일반적 판단방법] i) 사후적고찰을 해서는 안되며(判例) 출원시를 기준으로, 당업자의 입장에서 청구항에 기재된 발명과 제29조1항 각호에 기재된 발명을 비교 하여 구성의 곤란성, 목적의 특이성, 효과의 연계성을 참작하여 판단한다. ii) 인용발명의 내용이 청구항에 기재된 발명에 이를수 있는 동기가 될 수 있는 지, 양발명의 차이가 당업자가 가지는 통상의 창작 능력에 해당하는지, 인용발명과 비교하여 더 나은 효과가 있는지를 참작하여 판단한다.

(2) [구체적 판단방법] i) "발명에 이를수 있는 동기가 있는 것" - 인용발명의 내용중 출원발명에 대한 시사가 되어 있거나 양발명의 기능과 작용이 공통되는 경우, 해결과제가 공통 되는 경우, 기술분야의 관련성이 있는 경우 등은 용이하게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다.

ii) "통상의 기술자의 통상의 창작능력의 발위에 해당하는 것" - 공지기술의 일반적 응용, 알려진 물리적 성질로부터의 추론, 알려진 과정의 해결위안 다른 기술분야 참조등 일상적 개선을 이루는 것은 용이하게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다. 구체적인 유형으로, 일정목적 달성을 위한 공지의 재료 중 가장 적합한 재료의 선택, 수치범위의 최적화 또는 오적화, 균등

물에 의한 지원, 기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경, 일부구성요소의 생략, 단순한 용도의 변경 등이 있다. iii) "더 나은 효과" - 인용발명에 비하여 이질적 이거나, 동질이 지만 연계한 효과가 있는 경우에 이는 진보성 판단에 긍정적으로 참작할 수 있다.

(3) [참고적 판단방법] i) 判例는 상업적 성공이나 장기간의 미해결 과제 등을 참작할 수 있으나 그 자체만으로 진보성을 단정할 수는 없다고 하며 ii) 그 밖에도 실시어락과 경영자의 묵인, 침해자들의 모방과 칭찬의 언동, 비슷한 시기의 동일, 유사발명의 완성사실들이 진보성 판단하는 근거로 사용될 수 있다는 논의가 미국 判例들을 중심으로 이루어지고 있다.

(4) [기타 판단방법] i) 출원발명 전체로서 판단하여야 하고 ii) 물건발명이 용이하게 발명할 수 없다면 제법발명, 용도발명도 용이하게 발명할 수 없다. iii) 마쿠쉬청구항은 1요소를 택해 판단 결과 용이하게 발명할 수 있다면 전체가 용이하게 발명할 수 있는 것으로 본다.

III. 설문(2)에 대하여 - 각 발명의 특유한 진보성 판단방법

1. 선택발명

i) 선택발명이란 선행발명을 상위개념으로 하여 하위개념에 있는 발명이다. ii) 심사실무는 공지기술로부터 실업적으로 직접 또는 오적한 것을 선택한 정도의 발명은 진보성을 인정하지 않고. 인용발명에 비해 더 나은효과를 갖는 경우 진보성을 인정한다. iii) 判例는 선택발명이 선행발명과 이질적이거나 동질이지만 연계한 효과를 가지는 경우 진보성을 인정한다. iv) 判例는 선택발명의 상세한 설명에 연계한 효과를 명확히 기재하면 충분하고 비교실업 자료까지 기재해야 하는 것은 아니며 만일, 효과가 의심스러울 때에는 출원인이 비교실업 자료를 제출하여 효과를 입증할 수 있다고 한다. v) 判例는 효과를 명확히 기재하기 위해서는 상세한 설명에 질적인 차이가 확인 위한 구체적 내용이나 양적으로 연계한 차이가 확인 위한 정량적기재가 있어야 한다고 한다. vi) 출원 명세서에 의해서 진보성이 판단되어지는 특수성으로 인해 명세서 기재불비와 진보성은 법조문이 명백히 다름에도 일관된 법해석이 마련되어 있지 않으며 vii) 신규성과의 관계에서도 진보성과 일원적으로 보는 견해 있으나 判例는 이원적으로 각각 나누어 판단한다.

2. 결합발명

i) 결합발명이란 발명의 기술적 과제 달성을 위해 선행기술들에 기재된 기술적 특징을 중합하여 새로운 해결수단으로 구성한 발명이다. ii) 결합발명은 진보성유무에 따라 공지기술의 단순한 집합인 주합발명과 새로운 결합인 조합발명으로 구별된다. iii) 判例는 청구항이 복수의 구성요소가 되어 있는 경우 진보성 판단함에 있어서 유기적으로 결합한 전체로서의 구성의 곤란성을 따져야 하며, 이때 결합된 전체구성의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다고 한다. iv) 결합발명의 진보성은 2이상의 선행기술을 상호 결합시켜서 판단할 수 있으나, 결합이 당업자에 용이하여야 한다.v) 과거 미국의 경우, 복수의 선행기술이 결합하는데 Teaching, Suggestion, Motivation가 존재하는 경우에만 진보성을 부정하는 이른바 'TSM 테스트'를 지나치게 고수하여 결합발명의 진보성획득이 쉬워져 특허남발을 초래 하였다. vi) 判例는 인용기술의 결합이 출원발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술에 제시되어 있는지 여부를 주로 참작하여 판단하나 암시, 동기 등이 없더라도 당업자가 용이하게 발명할 수 있다면 진보성

을 부정할 수 있다고 판시한바 이는 TSM 테스트를 채용해온 CAFC의 오랜 태도에 계동을 건
미 연방대법원의 KSR 판결과 궤를 같이하는 판지로 보인다.

3. 제법안정물건발명

i) 제법안정물건발명이란, 물건에 관한 발명을 구성이 아닌 제조되는 방법으로 특정한 발명이
다. ii) 심사실무는 방법적 형식으로 기재한 물건에 관한 청구항에 있어서 보호받고자 하는 대
상은 물건 자체로 해석되므로 “물건 자체”의 구성을 공지된 물건의 구성과 비교하여 진보성
여부를 판단하여 특허여부를 결정한다. iii) 判例는 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수 밖에
없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 제조방법 자체는 고려할 필요 없이 물건으로 특정되는 발명
만을 출원전에 공지된 발명과 비교하면 된다고 한다. iv) 등록후 해당 제조방법에 안정하여 물
건에 권리범위가 미친다는 안정설에 따르면 진보성판단 역시 제조방법도 함께 고려하지만 v)
특허법이 물건발명과 제법발명을 나누고 있는 점, 제조방법은 구성을 특정하기 위한 수단에 불
과하다는 점, 개정법이 제42조4항3호를 삭제한 점 등을 고려 하면 제조 방법이 달라도 권리범
위가 미치며 진보성판단 역시 물건자체를 기준으로 하는 동일성설을 취하는 것이 타당하다. vi)
다만, 권리침해단계에서는 제조방법에 안정될 수 있고 (判例) 제조방법 기재로 심사지연을 초래
할 수 있으므로 제조방법에 기술적 특징이 있다면 방법발명으로 출원하는 것이 유리 할 것이다.

Ⅰ. 문제의 소개

<A-2>

특허법은 발명의 다면적 보호를 위해 다양제를 채택하며, 권리범위와 자유기술영역의 한계를 명
확히 하고, 분쟁의 경우 신속한 침해판단을 위해 청구항을 독립항과 종속항으로 구별하고 있다.

Ⅱ. 설문(1)에 대하여 - 독립항과 종속항을 구분하는 일반적인 기준

1. [시행령 제5조 1항] 특허청구범위에는 독립항을 기재하고 그 독립항을 인용하는 형식으로 안
정·부가 (상위개념을 하위개념으로 안정하거나 기술구성을 부가) 하여 구체화하는 종속항으로
기재하며 그 종속항을 안정·부가하여 구체화하는 다른 종속항으로 기재할 수 있다.

2. [의의 및 구별방법] i) 종속항이란 청구항의 내용이 다른 항에 종속된다는 의미로서 다른항
의 내용변경에 따라 당해 청구항 내용이 변경되는 청구항을 말하고, 인용하는 형식을 취하며 실
질적으로 인용되는 항을 안정·부가하여야 한다. ii) 독립항은 인용하지 않는 독립형식으로 기
재하나 동일사상의 중복기재 피하기 위해 일정범위 내에서는 인용하는 형식으로 기재가능하다.

3. [判例] 판례는 인용하는 형식이라도 인용되는 항을 안정·부가하여 구체화하는 것이 아니면
독립항으로 보는바, 인용되는 항의 구성요소를 감소하거나 치환하는 경우 독립항으로 취급된다.

4. [검토] i) 따라서 인용항을 종속항으로 보는 안정해석이 아닌 인용하는 항이 인용되는 항의
내용을 실제적으로 안정 또는 부가하여 하고 있는지로 판단하는 서술적 해석을 하여야 할 것이
다. ii) 인용형식의 독립항은 인정(서술적 해석) 하면서도 구성요소 치환 형식의 청구항을 붙여
(안정해석) 했었던 종전의 혼란스러운 태도는, 상이한 성격을 갖는 특허법 임에도 불구하고 충분
한 검토 없이 일본과 미국에서의 제도 및 해석을 도입한 점에서 기인한 것으로 보인다.

Ⅲ. 설문(2)에 대하여 - 각 청구항을 독립항 또는 종속항으로 구분

1. [청구항 1] 다른 청구항을 인용하지 않고 독립형식으로 기재된 최초 청구항으로 독립항이다.

2. [청구항 2] i) ‘제1항에 있어서’ 라고 표현된바 독립항인 제1항을 인용하는 형식을 취하고 있으며 ii) 제1항 발명의 구성요소인 ‘노즐’ (상위개념)을 ‘분사구의 형태가 원형인 노즐’ (아위개념) 로 한정하여 구체화 하였으므로 설문(1)에서의 구별기준에 의할 때 종속항에 해당한다.
3. [청구항 3] i) ‘제2항에 있어서’ 라고 표현된바 종속항인 제2항을 인용하는 형식을 취하고 있으나, ‘인용되는 항을 한정·부가하여 구체화’ 하였는지에 대해 복수의 해석이 가능하다. ii) 형식적으로 인용되는 제2항과의 관계에서만 판단하게 되면 제2항 발명의 구성요소 중 노즐의 분사구 형태를 원형에서 4각형으로 치환한 것에 불과한바, 한정·부가하여 구체화 한 것으로 볼 수 없어 독립항으로 해석될 수 있다. 이 경우 독립항임에도 중복기재를 피하기 위해 제2항을 인용한 것으로 본다. iii) 다만, 종속항은 상기 살펴본 바와 같이 인용하는 형식을 취하고 ‘실질적으로’ 인용되는 항을 한정·부가하여야 하는 것이므로 제3항은 제2항을 인용하지만 제2항은 제1항을 인용하고 있는바 제3항은 실질적으로 제1항을 인용하고 있다고 판단된다. 따라서 제1항과의 관계에서 살펴보면 ‘노즐’ (상위개념)을 ‘분사구의 형태가 사각형인 노즐’ (아위개념) 로 한정하여 구체화하였으므로 종속항으로 보는 것이 타당할 것이며 이것이 독립항과 종속항을 구별하는 취지 및 다양계를 채택하고 있는 우리법의 취지에도 부합하다.
4. [청구항 4] i) ‘제1항에 있어서’ 라고 표현된바 독립항인 제1항을 인용하는 형식을 취하고 있으나 ii) 제1항 발명의 구성요소인 ‘복수 개의 노즐’ 을 ‘하나의 노즐’ 로 치환하였으므로 인용되는 제1항을 한정하거나 부가하여 구체화한 것으로 볼 수 없는바 독립항에 해당한다.
- IV. 설문(3)에 대하여 - 청구항1 내지 4의 진보성 판단의 상호관계
1. [문제점] 설문(2)에서 검토한 바와 같이 제1항과 제4항은 독립항이고, 제2항과 제3항은 독립항인 제1항의 종속항으로 구별되는바, 각 항들의 진보성 판단시 상호관계에 대하여 논아겠다.
2. [진보성 판단] 진보성 판단은 청구항별로 전체로서 고려하여 판단하여야 하며 출원일체의 원칙에 의해 어느 한 청구항이라도 진보성이 없으면 당해 출원은 등록받을 수 없다.
3. [진보성 판단시 독립항과 종속항의 관계] 判例 및 실무는 i) 독립항의 진보성이 인정되는 경우에는 그 독립항에 종속되는 종속항도 진보성이 인정되나, ii) 독립항의 진보성이 인정되지 않는 경우에는 그 독립항에 종속되는 종속항에 대하여는 별도로 진보성을 판단한다고 한다.
4. [제1항의 진보성이 있는 경우] 독립항인 제1항이 진보성이 인정되는 이상 제1항의 종속항인 제2항과 제3항은 별도로 진보성 판단을 요하지 않고 당연히 진보성을 가진다. 제4항은 독립항이므로 제1항 내지 제3항의 진보성판단 결과와 무관하게 별도로 판단하여야 할 것이다.
5. [제1항의 진보성이 없는 경우] 독립항 제1항의 종속항인 제2항과 제3항은 제1항의 ‘노즐’ 을 ‘분사구의 형태가 원형인 노즐과 사각형의 노즐’ 로 각각 한정하였으므로, 노즐의 분사구 형태의 차이를 중심으로 제1항과 별도로 제2항과 제3항의 진보성을 판단하여야 하며 제4항은 독립항이므로 제1항 내지 제3항의 진보성판단 결과와 무관하게 별도로 판단하여야 할 것이다.
6. [청구항 3을 독립항으로 보는 경우] i) 제1항이 진보성이 있으면 제2항은 당연히 진보성을 가지며 ii) 제1항이 진보성이 없으면 제2항은 별도로 판단하여야 할 것이다. iii) 또한, 제3항과 제4항은 독립항이므로 제1항과 제2항의 결과와 무관하게 별도로 판단하여야 할 것이다.